

法經濟學與中國司法實踐^{*}

—— 法律人思維的一個註腳

張巍^{**}

摘 要

本文通過回答「什麼樣的司法體系更容易將法經濟學的視角納入司法實踐」與「什麼樣的制度條件下更（不）應該將法經濟學的視角納入司法實踐」這兩個問題，剖析了法經濟學對中國司法實踐的意義，認為基於中國司法體制的現狀，目前不宜在司法實踐中推進法經濟學的視角。此外，本文也分析了法教義學與法經濟學思維模式的區別，並借助幾個典型案例比較法教義學與法經濟學在司法實踐中的作用。

關鍵詞：法經濟學、法教義學、法律人思維、司法積極主義、司法實踐。

* 本文部分內容取自筆者2014年6月於臺灣中央研究院法律學研究所第四屆兩岸四地法學研討會上的發言；並曾刊載於《法律和社會科學》2015年第14卷，頁249-276。

責任校對：林庭伊、呂佳霖。

** 新加坡管理大學法學院助理教授。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/83615071.pdf>。



目 次

壹、實證性問題	三、稅收再分配機制的有效性
一、對司法積極主義的容忍	四、中國的情況
二、法官審判的獨立性	參、法教義學與法經濟學
三、兩方面的組合	一、二者有無區別？
四、中國的情況	二、法經濟學指導司法實踐有無優勢？
貳、規範性問題	肆、誰的法律思維？（代結論）
一、法官的自制	
二、國民對司法體系的認同	

法經濟學研究在中國日益蓬勃發展，尤其在中青年法學研究者中間逐漸成為一個熱門的研究領域。芝加哥大學法學院近年來專門針對中國的學者開辦了暑期的法經濟學培訓班，也廣受歡迎。中國許多一流的法學院校，如北京大學、中國人民大學、浙江大學、中國政法大學等都設立了法與經濟學的研究中心，中國法經濟學會也已成立多年。然而，對於大熱的法經濟學，也許我們需要更多一些冷靜的思考。

尤其值得指出的是：法經濟學首先是一門研究規則的社會科學，而非一幅可以直接用以指導司法實踐的技術圖紙。從事科學研究者的目的在於探尋真理，而從事技術實踐者的目的則在於解決問題。就此二者不同的出發點論，筆者以為近來中國法學界有關「法律人思維」的爭論¹，似乎都沒有釐清「法律人」究竟指的是誰。

¹ 參見蘇力，法律人思維？，北大法律評論，2013年第2輯，頁429-469（2013年）；孫笑俠，法律人思維的二元論兼與蘇力商榷，中外法學，2013年第6期，頁1105-1136（2013年）；桑本謙，「法律人思維」是怎樣形成的——一個生態競爭的視角，法律和社會科學，2014年第1期，頁1-25（2014年）。

質言之，法律研究者與司法實踐者的思維或許本就應該有所不同，而將二者不加區分，籠統地給他們按上一種思維模式，恐怕並不合適。學者從各自預設的那部分法律人出發，主張這部分人應當具備的思維模式就是所謂「法律人」的思維模式，則無疑將陷入「關公戰秦瓊」的議論困境。

本文主要從司法體系的構造與運行條件出發，試圖分析為何法經濟學在中國的司法實踐中沒有風行，也不應當風行。基於這些分析，筆者認為教義法學仍應是中國法律實踐者的首要思維方式。文章以下分為三個部分。第一部分回答「什麼樣的司法體系更容易將法經濟學的視角納入司法實踐？」這一實證性（positive）問題；第二部分回答「在什麼樣的制度條件下更（不）應該將法經濟學的視角納入司法實踐？」這一規範性（normative）問題；第三部分借助既有文獻中的幾個具體案例，簡要說明法經濟學的解釋與法教義學的解釋一樣面臨諸多困境。

壹、實證性問題

針對第一個問題——什麼樣的司法體系更容易將法經濟學的視角納入司法實踐——筆者認為，從司法體系自身的特性來看，也許有兩個因素值得重視，即對司法積極主義（judicial activism）的容忍與法官審判的獨立性。

一、對司法積極主義的容忍

在規範意義上，法經濟學的政策指向非常明確，就是要追求法律規則的效率。並且，在操作層面上，法經濟學實際進行的是「成本—收益」分析，或者說是追求將蛋糕做得最大。因此，法經濟學的視角要求司法裁判直接體現特定的政策追求，這無疑需要以司法

積極主義的理念為依託。尤其當裁判涉及「難案」，無法直接形式地適用既有法律規則之時，效率導向的裁判是對政策問題的直接回應。

基於這種特徵，如果法經濟學的視角要在司法實踐中得以體現，那麼，對司法積極主義的一定程度的容忍看來是必不可少的。這種容忍一方面來自主權者，也就是說主權者能夠接受司法機構的職能不僅僅限於對主權者設定的政策的消極執行，有些時候——至少在不明顯違背主權者的既定政策的條件下——司法機構也可以積極推行其自身追求的某項政策。主權者的這種容忍能夠避免由憲法性的、結構性的設計引起的司法失權，從而無法實現其政策追求。同時，容忍也來自法律職業共同體內部。也就是說，在此職業共同體記憶體在一定的共識，即司法活動的功能不僅僅限於解決具體的糾紛，在一定範圍內，司法活動還肩負著推行特定政策的任務。法律職業共同體的這種共識直接決定著司法活動的第一線參與者是否願意根據一定的政策目標，有針對性地確定訴訟和法律執行策略，從而在反覆的嘗試中推動這一目標的前行。假如缺乏上述內外兩方面對司法積極主義的容忍，那麼，司法實踐恐怕很難直接且一貫地推進特定的政策目標，而效率作為這樣一種目標，也就不會在司法實踐中得到青睞。不過，這種容忍顯然只是司法實踐接納法經濟學視野的必要條件，而非充分條件，法律職業共同體——尤其是法官——在一定程度上認可效率作為司法的政策目標同樣必不可少。

二、法官審判的獨立性

法經濟學的視角很大程度上依託的是成本－收益分析，而這種分析不可避免地要涉及針對個案的具體判斷。一方面裁判者需要確定影響相關法律制度的成本與效益的變數，另一方面裁判者還需要估量在具體案件事實中這些變數可能的值域。換言之，要將法經濟學的視角納入司法實踐，必然需要法官在具體案件的裁判中行使相

當程度的司法裁量。而法官進行司法裁量的自由度受制於司法體系的構造，尤其是法官作為個體在審判中的獨立性。

在司法權力趨於水準分佈的司法體系中，法官的個體獨立性比較強，或者說，法官的行動更接近於一個「本人」——而非「代理人」——的行動。最為重要的是，法官個體的司法行為及其結果不會成為司法體系評判其優劣並實施獎懲的依據。反之，在司法權力趨於垂直分佈的司法體系中，法官個體的獨立性比較弱——即便司法體系本身具有獨立性。在此，法官的行動更加類似於一個「代理人」的行動，其司法行為及其結果會成為司法體系考評其優劣並給予獎懲的依據。儘管法官個體獨立性弱未必表明司法體系的獨立性弱，但這兩種獨立性很可能是相聯繫的。並且，司法的獨立性——無論個體還是體系——雖然可能與政體形態有相當關聯，卻未必完全對應。具體而言，集權制國家的司法獨立性整體較弱，但在特定條件下，集權政體也可能容忍一定程度的司法獨立²，而民主制國家的法官和司法系統也可能受到相當的政治壓力³。

在法官個體獨立性較弱的司法體系中，法官的司法裁量會趨於保守，其行為將表現得更為厭惡風險（risk-averse）。這是因為裁量不僅影響到法官內心的滿意程度——是否符合法官自身的口味，而且還會影響其面臨的外部條件——包括薪酬、職位、名譽等。而司法裁量對這些外部條件的影響具有不確定性（uncertainty），為減少這種不確定性給法官帶來的負效用（disutility），法官就可能尋求比

2 大革命前的法國是有名的例子，see William Doyle, *The Parlements*, in *THE FRENCH REVOLUTION AND THE CREATION OF MODERN POLITICAL CULTURE VOLUME 1: THE POLITICAL CULTURE OF THE OLD REGIME* 157 (Keith Michael Baker ed., 1987)；有關皮諾切特（Augusto José Ramón Pinochet Ugarte）治下智利的例子，see LISA HILBINK, *JUDGES BEYOND POLITICS IN DEMOCRACY AND DICTATORSHIP: LESSONS FROM CHILE* (2007).

3 有關自民黨治下日本的例子，see J. MARK RAMSEYER & ERIC B. RASMUSEN, *MEASURING JUDICIAL INDEPENDENCE: THE POLITICAL ECONOMY OF JUDGING IN JAPAN* (2003).

較穩妥的標準作為其裁量的依據。因此，一方面法官會樂於尋求同行廣為接受的標準而避免新鮮的標準，另一方面法官也可能更樂於接受裁量餘地相對較小的標準。總體而言，效率標準既不是法律共同體傳統接受的，同時——由於其不定性（indeterminacy）——也會帶來更大的裁量空間。所以，法官個體獨立性弱的司法體系更可能拒絕接受法經濟學的視角。

三、兩方面的組合

也許有人會發覺以上提到的兩個方面——對司法積極主義的容忍和法官審判的獨立性——與Mirjan R. Damaška提出的司法行為的目的與司法權力的結構這兩個維度的不同組合密切相關。的確，筆者的思路受到了Damaška理論的強烈影響。一方面，以政策實施為目標的司法體系比以糾紛解決為目標的司法體系更可能容忍司法積極主義；另一方面，協調型的權力結構比科層型的權力結構更可能保證法官審判的獨立性。照此分析，在表1中，最有可能接受法經濟學視角的司法體系應該是第III類。

表1 司法的目的與權力結構⁴

司法的目的			
司法權力結構	政策實施		糾紛解決
	科層型	I	II
	協調型	III	IV

不過，Damaška模型中以政策實施為目標的司法強調國家權力對司法活動的影響，而筆者在此提出的司法積極主義更側重於法官以及法律共同體以司法推進特定政策目標的實施。換言之，Damaška所謂的政策實施相對於司法體系而言可能是一種外生的目

⁴ See MIRJAN R. DAMAŠKA, THE FACES OF JUSTICE AND STATE AUTHORITY: A COMPARATIVE APPROACH TO THE LEGAL PROCESS 181 (1991).

標，而本文涉及的政策實施更是司法體系中內生的目標。當然，如前所言，這種內生的目標需要得到一定程度的國家權力的容忍。因此，如果嚴格按照Damaška的觀點，那麼，以政策實施為目的的司法體系也可能反而更不容易接受法經濟學的視角——假如效率並非國家權力追求的政策目標。反之，假如效率是國家權力追求的目標，則以政策實施為目的的司法體系將較以糾紛解決為目的的司法體系更容易接受法經濟學視角。不過，這一觀點是建立在「其他條件相同」的假設之上的，而最重要的其他條件就是司法權力的結構。儘管以政策實施為目的的司法體系可能更易於接受效率的觀點，然而，這種司法體系卻往往會與科層型的司法權力結構相聯繫，而後者會抑制司法活動對法經濟學視角的接納⁵。

與外生的政策目標不同，在司法積極主義之下內生的政策目標由於沒有外部權力的強制因素，更可能呈現相對多元的態勢。也就是說，不同的法官追求的政策目標會有所不同，而法律共同體也可能認可多重政策目標的組合並存。於是，內生的政策目標中更可能出現一定程度的效率追求。不過，雖然司法積極主義也會出現在科層型權力結構的司法體系中，但這種司法體系中的司法積極主義的程度通常會低於協調型的司法體系⁶。

在此，筆者要強調，本文僅僅試圖從司法體系的特徵中尋求影響司法實踐吸納法經濟學視角的因素，但並非認為這些因素是充分條件。顯然，除了司法體系的特徵因素外，法律教育乃至文化傳統等都可能影響法經濟學視角在一國司法實踐中的作用。

5 Damaška就曾明確指出：科層型權力結構的司法體系更容易排斥結果主義的司法標準以及實用主義的推理方法，DAMAŠKA, *supra* note 4, at 21-23，而法經濟學顯然是建立在結果主義與實用主義之上的。

6 有關日本的司法積極主義，see Hiroshi Itoh, *Judicial Review and Judicial Activism in Japan*, 53 LAW & CONTEMP. PROBS. 169 (1990).

四、中國的情況

在Damaška的分析框架之中，中國的司法體系應該屬於比較典型的第I類，即以政策實施為司法目的並以科層製作為司法權力的基本結構⁷。在這樣的司法體系中，無論主權者還是司法機構本身都對司法積極主義抱有相當正面的態度——儘管這種態度不一定為法律職業共同體的其他成員所接受。中國法院展開的所謂「能動司法」運動正是這種態度的體現⁸。不過，迄今為止，雖然效率可能被作為司法機構內部運作的一個考量因素⁹，卻並未成為司法裁決中直接追求的一項目標。因此，目前中國的司法實踐未普遍接納法經濟學的視角便不足為奇。然而，僅從對司法積極主義的容忍這一角度而言，法經濟學視角進入中國的司法實踐存在著胎動的可能性。尤其考慮到中國的整體政策導向傾向於經濟發展這一點，效率目標在司法活動中日益扮演重要角色並非不可想像¹⁰。

不過，中國司法體系的科層制特徵卻可能是對司法實踐接納法經濟學視角更加重要的制約。在中國目前嚴重結果導向的司法考核機制之下¹¹，法官總體的行為模式將偏向於厭惡風險和厭惡損失

7 儘管在中國條塊結合的政治權力結構中，不同層級的法院和法官可能受到多重本人的制約，但就單個的法院或者法官而言，其處於科層結構中一定層級的地位並無本質改變。當然，由於多重本人的出現，代理人的行為以及各代理人之間的關係會有所變化，這已超出本文論述的範圍。有關中國的條塊政治結構，參見KENNETH LIEBERTHAL, *GOVERNING CHINA: FROM REVOLUTION THROUGH REFORM* (2d ed. 2003)；有關多重本人的官僚結構，參見GORDON TULLOCK, *THE POLITICS OF BUREAUCRACY* (1965)；有關在多重外部制約下司法機構滿足自身偏好的條件，參見ROBERT D. COOTER, *THE STRATEGIC CONSTITUTION* (2000)。

8 關於能動司法的一個典型例證，參見楊豔輝訴中國南方航空公司、上海民惠航空公司客運契約糾紛案，（2003）徐民一（民）初字第1258號（法院判決後主動向被告的行政主管機構發出司法建議書，提出行業性的整改建議）。

9 See Taisu Zhang, *The Pragmatic Court: Reinterpreting the Supreme People's Court of China*, 25 COLUM. J. ASIAN L. 1 (2012).

10 譬如，「時間就是金錢，效率就是生命」的口號也曾響徹全國。

11 See Carl F. Minzner, *Riots and Cover-ups: Counterproductive Control of Local Agents in China*, 31 U. PA. J. INT'L L. 53 (2009).

(loss-averse)。因此，他們更可能採取避免裁量和縮減裁量幅度的做法，以減少嗣後因不被上級認同的裁量結果而承受不利益。尤其是處在一個制度化程度低、面臨各種外來壓力的司法體系中，法官的行為將更加趨於保守¹²。正如上海的一位中層法官所言，中國法官的基本行為模式可被形象地稱為「戴著鐐銬跳舞¹³」。法經濟學效率導向的分析視角，不僅與傳統的公平正義司法觀在直覺上形成突兀的對比，無論對社會一般公眾，還是對法律職業共同體而言都是一種新穎的概念，而且其分析方法也不為絕大多數法官熟知，分析結果也有著很大的不定性。所以，處於這樣的司法體制性制約之下，很難寄望戴著鐐銬的中國法官能在司法實踐中邁出法經濟學視角所需的新穎、大幅的舞步¹⁴。

貳、規範性問題

針對前面提出的第二項問題——什麼樣的制度條件下更（不）應該將法經濟學的視角納入司法實踐，筆者以為或許有三個方面值得考慮：法官的自制、國民對司法體系的認同，以及稅收再分配機

12 近年來，中國的司法體系不僅受到既有的政治壓力，see RANDALL PEERENBOOM, CHINA'S LONG MARCH TOWARD RULE OF LAW (2002)，還日漸受到媒體以及民粹主義（populism）的影響，see Benjamin L. Liebman, *Watchdog or Demagogue? The Media in the Chinese Legal System*, 105 COLUM. L. REV. 1 (2005); Benjamin L. Liebman, *Malpractice Mobs: Medical Dispute Resolution in China*, 113 COLUM. L. REV. 181 (2013) [hereinafter Liebman, *Malpractice Mobs*]; Carl F. Minzner, *China's Turn Against Law*, 59 AM. J. COMP. L. 935 (2011).

13 筆者與上海某中級人民法院法官的訪談，2013年7月4日。

14 本文並不否認中國法官在司法實踐中存在局部的創新衝動，see Rachel E. Stern, *On the Frontlines: Making Decisions in Chinese Civil Environmental Lawsuits*, 32 LAW & POL'Y 79 (2010)，不過，這種衝動背後的激勵因素還有待於進一步的研究。並且，從現有經驗證據看，這種衝動依然是個別性的，可能主要存在於某些具有強烈晉升欲望和一定晉升潛力的法官中間。此外，司法創新本身也不一定意味著法官乃至司法體系掙脫了鐐銬，獲得了自主性，因為創新仍可能因循特定的外部壓力，請見註12中Benjamin L. Liebman的2篇文章。

制的有效性。

一、法官的自制

儘管法經濟學的視角要求實施裁量，但這種裁量顯然不應該是任意妄為的，或者以司法裁量之名行謀求其他利益之實。否則，不但法律體系的穩定性和可預見性岌岌可危，也會引發司法體系自身的信任危機。無論是否接納法經濟學的視角，在一個成熟的司法體系中，法官對司法裁量都應有一定程度的自我約束，使自己的裁量不過分溢出於現行法律允許的範圍之外。誠如已故日本著名民法學家加藤一郎所言，即便法官以利益衡量作為裁判的直接線索，仍必須將由此得出的結論置於現行法的框架之下重新加以審視，假如利益衡量的結果與現行法的體系存在明顯的矛盾，則應當放棄前者而重新審度利益衡量的角度¹⁵。這種對裁量結果進行規則正當化的過程同樣也應該適用於運用法經濟學方法分析得出的結論。這既是對法律規則穩定性的維護，也是對司法功能的自覺約束。

就法經濟學方法在司法實踐中的運用而言，法官的自制十分重要。這在很大程度上是出於法經濟學方法的不定性。這種不定性一方面體現在：就特定的法律規則規範的社會關係而言，影響其效率的變數往往多種多樣，不同研究者通過選取不同的變數，可能分析得出不同的結論。儘管有學者認為，現實性與便宜性應當成為分析選取變數的原則¹⁶，但這兩個標準過於抽象，恐怕難以付諸實踐操作。例如，法經濟學者對於權利救濟的責任規則與財產規則效率優劣的莫衷一是，便體現出了這種因為變數選擇不同而產生的理論的不定性¹⁷。另一方面，法經濟學方法的不定性還表現為對於理論涉

¹⁵ 參見加藤一郎，民法における論理と利益衡量（1974年）。

¹⁶ See HOWELL E. JACKSON ET AL., ANALYTICAL METHODS FOR LAWYERS 442 (2d ed. 2011).

¹⁷ 這方面代表性的研究有 Louis Kaplow & Steven Shavell, *Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis*, 109 HARV. L. REV. 713 (1996); Ian Ayres &

及的變數缺乏有效的測度標準，以致於理論的最終分析結論不定，其規範性作用也就無法確定。這方面的典型表現是在法經濟學有關契約法的分析上¹⁸。此外，與這第二方面相關，即便有測度變數的合適方法，經驗研究的方法不當也可能造成不定的結果，從而至少在找到正確研究方法之前給實踐運用帶來困惑。這方面的突出例證是有關死刑震懾作用的研究¹⁹。

面對以上各式各樣的不定性，法官無論在選取模型、資料還是經驗結論方面都會有相當的自由裁量空間。因此，倘若沒有基本的自制，很難避免法官在裁量過程中不摻雜進其他不應有的考慮因素。在此意義上，即便在裁量中採用成本—收益分析的方法，也仍有必要遵循最低限度的法律形式主義要求，至少裁量的結果不能與法律的文義發生明顯的衝突。在強調司法獨立，尤其是法官個體獨立的司法體系中，這種形式主義的保障很大程度上取決於法官的自制。而這種自制又取決於長期的法律教育與法律文化的薰陶。要言之，本文所涉及的規範性問題的第一個命題就是：在法官整體缺乏自制傳統的司法體系中，法經濟學的視角不應被納入司法實踐。

二、國民對司法體系的認同

國民對司法體系的認同是確立司法體系正當性的基礎，在此基礎之上，國民才會願意選擇司法體系作為解決糾紛的途徑，也才會願意接受司法裁決的結果。在現代司法體系中，涉案當事人並未就

Eric Talley, *Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade*, 104 YALE L.J. 1027 (1995); Lucian Arye Bebchuk, *Property Rights and Liability Rules: The Ex Ante View of the Cathedral*, 100 MICH. L. REV. 601 (2001); Ian Ayres & Paul M. Goldbart, *Correlated Values in the Theory of Property and Liability Rules*, 32 J. LEGAL STUD. 121 (2003).

¹⁸ See Eric A. Posner, *Economic Analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?*, 112 YALE L.J. 829 (2003).

¹⁹ See John J. Donahue & Justin Wolfers, *Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate*, 58 STAN. L. REV. 791 (2006).

特定爭議事件適用的規則或者裁判的法官作出特定性認同，因此，對司法體系及其適用的規則的一般性認同就成為了司法體系發揮社會控制功能的合法性保障²⁰。由此，司法體系的合法性得以確立，不再需要尋求當事人就各項規則和各名法官一一認同。對司法體系的一般認同使得裁判者得以根據其認為恰當的實體和程式性規則對案件作出裁量與判斷。

正是有了一般性的認同，司法體系的運作得以專業化和效率化。換言之，即便專業的司法活動依賴的具體規則不為當事人理解，規則適用的結果仍然能得到當事人的信任與執行。因此，越是專業化的司法活動，越可能無法得到當事人的特定性認同——因為當事人越難理解規則及其適用的原理，於是，這樣的司法活動就越依賴國民對司法體系的一般性認同來取得合法性。遵循這樣的邏輯，我們不難看到：司法專業化的推進，要以國民對司法體系的認同為基礎，專業化程度越高，對這種認同的依賴也越深。

前面已經指出：法經濟學的分析視角給法官的裁量留下了大量的空間。同時，法經濟學的分析方法具有高度的形式主義和抽象性——經濟分析是建立在一定假設基礎上的模型化分析。尤其是當數學工具運用到法律的效率分析之中時，其專業化的程度大幅度提升，普通當事人對這種司法裁量的理解能力隨之下降，取得其對司法活動的特定性認同也就變得更為困難。不僅是分析方法的專業化，法經濟學以效率作為裁判追求的目標本身就較公平、正義，這種司法裁判的目標更難獲得當事人的特定性認同。一方面效率目標與人們對司法裁判理念的天然認識有差距，另一方面也是因為效率是比公平、正義更具有專業內涵的概念，而這種專業性的內涵加深了普通人理解的難度。

20 See MARTIN SHAPIRO, *COURTS: A COMPARATIVE AND POLITICAL ANALYSIS* (1981).

正是由於法經濟學的效率目標和形式分析方法具備高度的專業化，因此，司法實踐在採納其視角的時候，尤其需要獲得國民對司法體系的一般性認同。只有這樣，當事人才能容易接受在不為其理解的具體規則運行之下得到的裁判結論。於是，本文有關規範性問題的第二個命題就是：在缺乏國民對司法體系的一般性認同的法域，法經濟學的視角不應被納入司法實踐。

三、稅收再分配機制的有效性

無論在什麼樣的社會，效率都不會是唯一的目標，即便是主張效率的經濟學家也不會否認公平的價值，也有不少經驗研究表明不公平可能削弱經濟發展——至少從長期來看如此²¹。對於公平，法經濟學者一般的觀點是：法律體系——尤其是私法體系——不是實現公平目標的最佳機制，與之相比，稅收與再分配機制能更有效率地實現社會認可的公平目標²²。這種觀點的基本理論依據是福利經濟學第二定律，或者說是市場對於分配的中立性。

假如我們同時認可公平對於人類社會的價值——不僅是社會價值，也包含經濟價值——以及稅收再分配機制與法律體系在實現公平方面具有替代性——儘管前者或許在此方面更富效率，那麼，就應當認為在稅收再分配機制不奏效，不能肩負起實現社會公平的地

21 See Torsten Persson & Guido Tabellini, *Is Inequality Harmful for Growth?*, 84 AM. ECON. REV. 600 (1994); Stephen Knack & Philip Keefer, *Does Inequality Harm Growth Only in Democracies? A Replication and Extension*, 41 AM. J. POLIT. SCI. 323 (1997); Philip Keefer & Stephen Knack, *Polarization, Property Rights and the Links Between Inequality and Growth*, 111 PUB. CHOICE 127 (2002); Daniel Halter et al., *Inequality and Growth: The Neglected Time Dimension*, 19 J. ECON. GROWTH 81 (2014). 不過，對此也存在相反的證據，see Kristin J. Forbes, *A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth*, 90 AM. ECON. REV. 869 (2000).

22 See Louis Kaplow & Steven Shavell, *Why the Legal System Is Less Efficient Than the Income Tax in Redistributing Income*, 23 J. LEGAL STUD. 667 (1994); LOUIS KAPLOW & STEVEN SHAVELL, *FAIRNESS VERSUS WELFARE* (2002); ROBERT D. COOTER & THOMAS ULEN, *LAW AND ECONOMICS* (6th ed. 2012).

方，依靠法律體系來實現公平目標就越具有重要性和迫切性。在缺乏最有效的實現公平的工具的地方，次優的工具越有用武之地。儘管對這種次優工具的運用也可能存在一個最優的限度，而且，在平衡狀態，靠這種次優工具實現的公平也許在程度上要低於運用最有效工具實現的公平，然而，完全放棄使用次優的工具顯然會令我們更加遠離我們珍視的公平目標。

其實，以上的邏輯也可以通過經濟學上簡單的邊際理論加以說明。如果將法律體系與稅收再分配機制視為具有替代性的實現公平的方法，那麼，其中一者發揮作用的程度越低，另一者的邊際效用就越高。因此，我們可以得到本文所涉規範性問題的第三個命題：在缺乏有效的稅收再分配機制實現公平目標的國家，法經濟學強調的效率不應成為司法實踐追求的主要目標。

四、中國的情況

如果參照以上的三個命題，不難得到這樣的結論，即中國目前不適於在司法實踐中引入法經濟學的視角。首先，中國的法官自製程度還很有限。一方面，中國的法律職業共同體還在逐步形成的過程中，法律教育也有待進一步系統化、規範化，這些都使得職業共同體內的價值觀念還比較紛雜。法官的來源雖然近年來已經變得較為專業化，但是，仍有相當部分法官——尤其是資歷深的法官——並未接受過系統的法律教育。由於教育背景與價值取向的不同引起的職業文化的多元化，使得法官的自我約束，亦即第一方的控制（first-party control）²³效果比較弱。而另一方面，中國社會的各種政治、民粹因素卻又很強大，對司法活動的影響強烈。再加之整體腐敗狀況嚴重，法官也深受腐蝕²⁴。這幾方面的因素相互疊加，削

23 See ROBERT C. ELLICKSON, *ORDER WITHOUT LAW: HOW NEIGHBORS SETTLE DISPUTES* (1991).

24 See Ling Li, *Corruption in China's Courts*, in *JUDICIAL INDEPENDENCE IN CHINA*:

弱了中國法官在進行司法裁量時恪守職業標準底線的動力。法官可能按照種種政治的、經濟的需要，而非按照合理的法律邏輯進行裁量。實際上，自最高人民法院以降，目前中國的司法裁判不知其法源所本的已經比比皆是²⁵。如果再允許法官添加上法經濟學的效率目標，它就可能成為潛在的政治、經濟影響的另一種體面包裝²⁶。

其次，中國公眾對司法體系還存在嚴重的不信任²⁷，而司法機構專業能力的加強並未改變這種不信任²⁸。相反，由於司法系統缺

LESSONS FOR GLOBAL RULE OF LAW PROMOTION 196 (Randall Peerenboom ed., 2010).

25 任舉一例，最高人民法院允許銀行在對其客戶違約的案件中僅僅承擔補充責任（見棗莊礦業（集團）有限公司柴里煤礦訴華夏銀行股份有限公司青島分行、青島保稅區華東國際貿易有限公司聯營契約糾紛案，（2009）民提字第137號），而無論是《契約法》還是最高院相關司法解釋都沒有違約者可以承擔補充責任的規定，法院的判決書也完全沒有引用相關的法律條文。這一做法似乎也為各地法院接受，如上述最高院再審案件的一、二審判決（山東省滕州市人民法院（2005）滕民初字第2716號、山東省棗莊市中級人民法院（2006）棗民四終字第105號）。同樣，即便是侵權責任，中國現行侵權法律也沒有規定銀行侵害客戶財產權可以僅承擔補充責任，而法院卻又會不知所據地作出這樣的判決（如信達投資訴浦發銀行長寧支行財產損害賠償案，上海市高級人民法院（2011）滬高民五（商）終字第22號）。

26 波斯納法官也曾類似提到形式主義司法更易於抵制權力干預，因此更加適合中國的集權政治體制，see Richard A. Posner, Lecture to the Students in the Summer School in Law and Economics (July 12, 2012) (unpublished manuscript, on file with The University of Chicago Law School)。不過，筆者在此著重突出形式主義司法更容易令非法的裁判因素——包括政治干預、經濟賄賂等——被察覺，桑本謙（註1），頁1-25，也有類似觀點，而對形式主義司法是否真的足以抵制政治權力並無確信。波斯納法官還指出中國的法官缺乏社會實踐經驗，因而不能勝任以實用主義為皈依的法經濟學分析，see Posner, *supra*。筆者認為這一因素進一步增加了法官自制的重要性——面對缺乏經驗的工作，更需要認識到自身的不足，在裁量中採取自我克制的態度。另外，值得指出的是：中國以及大陸法系其他地方的職業法官制度與其司法體系的科層型權力結構或許有密切關係——科層結構制約了法律職業共同體內人才的平行流動，譬如，有經驗的律師很難進入司法體系從初級法官做起，而直接在科層體系中取得中、高級地位又與科層制的內在邏輯不合，最多只能是例外情況。

27 Liebman, *Malpractice Mobs*, *supra* note 12, at 243.

28 See Mary E. Gallagher, *Mobilizing the Law in China: "Informed Disenchantment" and the Development of Legal Consciousness*, 40 LAW & SOC'Y REV. 783 (2006).

乏獨立性，法院的公正性受到普遍質疑，司法的專業化很可能進一步令公眾感到難以理解裁判的合理性，從而加深對司法體系的疑慮。如前所述，在缺乏國民一般性認同的司法體系中，裁判的正當性更加依賴當事人對特定裁判的特定性認同，而這種認同的前提就是能讓當事人理解裁判依據的規則與法官推理的過程。高度專業化的法經濟學分析方法，對於拉近法院與當事人的距離，取得當事人特定性認同可能有害無補，從而使得司法體系更加孤立於國民大眾，降低其制度上的重要性。

最後，中國現行的稅收與再分配機制顯然沒有能夠有效發揮調整收入分配，促進社會公平的作用。一方面，中國城鎮居民——尤其是高收入居民——的隱形收入占整體收入的比重相當高²⁹，而這部分收入不納入正式的收入統計，自然也無法成為所得稅的計徵對象。另一方面，中國現行的再分配體制嚴重不平衡，二次收入分配非但沒有起到減小收入差距的作用，相反還可能促進了實際收入差距的擴大。譬如，養老、退休金收入的差距貢獻了25%的城鄉收入差距，成為造成城鄉收入差距的一個重要原因³⁰。對此，清華大學秦暉教授提出了有名的「負福利」理論³¹。他指出中國的再分配機制未能給予低收入人群適當的福利，相反，卻為部分強勢集團創造了特權。前文已經闡明，在稅收與再分配機制失效的地方，即使遵循法經濟學家們的理論邏輯，也更應突出公平價值在司法實踐中的地位，而弱化對效率的追求。

29 王小魯，灰色收入與國民收入分配，王小魯的學術主頁，2010年7月30日，<http://mcrp.macrochina.com.cn/u/54/archives/2010/2035.html>。

30 西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心，中國家庭收入差距報告，2013年，<http://chfs.swufe.edu.cn/upload/shourubupingdeng.pdf>。

31 參見秦暉，共同的底線（2013年）。

參、法教義學與法經濟學

一、二者有無區別？

本文以上的分析指出：基於中國司法體系的構造與運行條件，我們不應提倡在司法實踐中採用法經濟學的思維方式。這一觀點的一個衍生結論是：至少就目前而言，中國的司法實踐者主要應採用教義法學的思維方式。那麼，到底有沒有教義法學的思維方式呢？要回答這個問題，只要比較教義法學者的主張與法經濟學者有關法律適用的主張是否有所不同。假如二者確有不同，就很難否認在法經濟學的思維方式之外別無教義法學的思維方式。對此，筆者以為二者至少有兩點重要區別。其一，二者對法律目的及其實施結果在法律適用中扮演的角色認識不同。其二，二者對成文法文義在法律適用中的作用認識不同。

首先，教義法學並非不考慮法律的目的、不體察法律實施的後果，以法律目的為出發點的教義法學解釋方法屢見不鮮³²。不過，其與法經濟學體察目的、結果的區別至少有以下兩個方面。一方面，教義法學對目的、結果的考察處於補充性地位，唯當法律文義不明，且無法從法律內在體系釋明文義之時，方才考慮目的及適用結果的合目的性。反之，於法律文義清晰，可直接通過三段論適用時，則目的問題不會在法律適用中彰顯出來。不僅如此，教義法學考察法律適用的結果是否符合法律的目的往往並非貿然行事，而是有一個試錯演變的過程。譬如，日本民法第177條有關不動產物權變動不登記不得對抗第三人的規定並未對「第三人」的範圍直接加以限制。由此，日本法院早先的判決也未對此作出限制。直到民法典施行十年之後的1908年方由當時的日本最高法院參酌法律為保護「對於主張登記欠缺具有正當利益者」之目的，而將「第三人」的

32 參見楊仁壽，法學方法論（1999年）；梁慧星，民法解釋學（1995年）。

範圍加以縮限，以將侵害不動產權利的侵權人排除出去³³。

與此相對，在法經濟學的思維中，目的追求是第一位的，具體而言，就是追求效率是法律的首要——若非唯一的話——目的。因此，在法律的每一次適用中這一目的都要彰顯出來。同時，對於多數法經濟學者而言，效率這一目的幾乎是先驗的，因為正如 Coleman 所言³⁴，法經濟學者並未就為何效率應當成為法律追究的目的作出有力的說明。而既然這一目的是先驗的，那就不存在發生錯誤的問題，於是，在法律適用中對此也沒有試錯的必要。

另一方面，相對於法經濟學的效率一元論，教義法學考慮的法律目的更加多元，而其中最為重要的就是公平。對於公平，法經濟學者一般的批判意見是其含義模糊不明。但是，即便公平含義不明，也不能否定公平是與效率不同的一個目的——假使法經濟學者認為效率含義明確，那麼，公平的含義不明正好體現其與效率的不同。況且，含義不明也不足以否認公平可以成為具有道德哲學（deontology）支撐的法律之目的。

迄今為止，筆者所見對於公平作為法律目的最為大膽的否定是桑本謙³⁵，其以進化論的觀點認為「效率和公平是一回事³⁶」。然而，這種將公平與效率等同起來的觀點不無疑問。其一，假如進化要求公平與效率趨同，那麼，經過進化得以留存的社會，其法律甚至其他的制度規範也應該趨同——因為效率之外別無其他進化選擇的條件，而若效率又是有統一確定的含義。事實顯非如此，不用比較現存的經濟發達社會與欠缺發達社會的法律制度，即便同等發達的德國與英國，其宏觀法律制度有顯著分別，這已是法律人的常

33 參見內田貴，民法I總則・物權總論，2版，頁445（2000年）。

34 See Jules Leslie Coleman, *The Grounds of Welfare*, 112 YALE L.J. 1511 (2003).

35 桑本謙（註1），頁1-25。

36 此前，即便最為徹底否認公平之於法律之價值的KAPLOW & SHAVELL, *supra* note 22，也承認公平與效率不是一回事。

識。從具體微觀的法律制度論，甚至同屬大陸法系，又同樣經濟發達的德國與日本，差別也可謂俯拾即是——如物權變動的要件。並且，在法經濟學者看來，這些制度差別的確具有效率差別³⁷。其二，即便承認進化的最終結果可以令公平與效率合二為一，也同樣無法否認進化過程中這兩者仍舊可能分別。由於進化過程的漫長，這種分別更可能長期存在。我們也無法知道當下的人類社會究竟處於進化的哪一環節，所以也無法遽然承認當下的公平與效率觀已經是一回事了。其三，縱使我們已經處在公平觀進化的終點，也無法否認公平與效率可以不同，因為在統一的效率觀念之下同樣可以出現不同的規則選擇，而當對一種規則的選擇明顯多於其他規則時，指引這種選擇的就只能是效率以外的其他目的。這方面的經典例證是對終局博弈（ultimatum game）的實驗性研究³⁸。儘管在此類博弈中，從博弈人角度看符合效率要求的金錢分配方式多種多樣，可是接近均等的分配方式則明顯受到博弈人的青睞。基於以上三點理由，筆者無法贊同公平與效率合二為一的觀點。

最後，在說明教義法學與法經濟學的第二項區別之前，筆者想強調：教義法學對法律目的的考察並不必然排斥效率，而只是認為有比此更加重要的目的，即公平正義，假如兩項目的發生衝突，則效率或應讓位於公平³⁹。

教義法學與法經濟學思維方式的區別還在於二者對文義在法律適用中的地位認識不同。在教義法學看來，法律文義不僅是解釋的

37 研究與法系相關的效率差異的 Rafael La Porta et al., *Law and Finance*, 106 J. POLIT. ECON. 1113 (1998)，已成為重要文獻。有關物權變動要件產生的效率差異，參見 Thomas J. Miceli et al., *Title Systems and Land Values*, 45 J.L. & ECON. 565 (2002)。

38 See Werner Güth et al., *An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining*, 3 J. ECON. BEHAV. 367 (1982)。

39 在此意義上，教義法學是以道德哲學為基礎的，而正如 Coleman (Coleman, *supra* note 34, at 1538-39) 所言，道德哲學家並不認為福利或者效率不應成為法律的目的，只是不認為其應該是法律的唯一目的。

起點，也是解釋的歸宿。為此，一方面，在對法學的宏觀認識上，教義法學突出解釋論與立法論的分野，解釋論絕不可超越文義許可的最大範圍，在此範圍之外的法學理論則屬於立法論的範疇。儘管法律的文義無可爭議地具有模糊性，但對其核心含義人們也同樣無可爭議地存在相當共識——否則語言文字即無法達成人際資訊交流地基本功能。正如「指鹿為馬」，人所不齒。教義法學在此方面的實踐，譬如，日本民法上曾經存在抵押權滌除制度，無論學界還是司法、金融實務界均將其詬病為損害抵押權人利益的禍水，或是「無用之累贅」。縱使如此，在法律修正之前，日本法院從未逕行否定滌除的效力，而是採取了根據法律文義儘量縮小其適用範圍的做法。其中一個具體的例子是：由於法律規定的滌除權人包括所有權、地上權或永小作權的取得者，而判例對於讓與擔保已採擔保權說，故而1997年日本最高法院將讓與擔保權人排除在滌除權人之外⁴⁰，直至2003年日本民法典修正，綿延百餘年的滌除制度方才壽終正寢。

另一方面，在對法律解釋方法的微觀認識上，教義法學強調文義解釋的首要地位和最終約束力，借此構築起一套解釋原則。即便在進行漏洞補充時，也要依據文義判斷確為立法之缺失方可補充。並且，漏洞補充這一司法行為本身也需要有法律的文辭作為基礎，如臺灣民法第1條，瑞士民法第1條等⁴¹。即便是教義法學中最為激進的利益衡量學說，也強調衡量的結果必須能穿上法律的外衣，假如的確無法穿上這件外衣，則需要放棄衡量而非法律⁴²。此外，教義法學還定下了諸如「禁止向一般條款逃逸」等規則限制法官脫離文義、過度裁量。

40 張巍，日本的抵押權滌除制度，民商法論叢，24卷，499-568頁（2002年）。

41 楊仁壽（註32），頁144。

42 參見加藤一郎（註15）。

與教義法學重視文義的地位不同，法經濟學重視的是法律適用的後果是否符合效率。在此意義上，假如根據文義適用法律無法滿足效率要求，則文義本身是不足以成為對法官裁量的拘束的。由此，法經濟學的思維在本質上不存在解釋論與立法論的分別。於是，在身處普通法系的法經濟學者看來，是否嚴格遵從先例成為了法院的資訊成本是否大於當事人的交易成本的問題⁴³。而桑本謙在論述允許撤銷贈與契約的理由時⁴⁴，顯然也將《契約法》不允許經公證的贈與契約撤銷的規定拋在了一邊——既然能以最低成本避免事故的一方不會因為公證而改變，法律在此作出區別性規定便是不符合效率的，從法經濟學的立場上看，這條法律就是應當修正的。

以上論述表明教義法學與法經濟學的思維方式確有不同。歸根究柢，教義法學比法經濟法學更加強調法律適用的形式，而法經濟學則比教義法學更加注重法律適用的結果。也可以認為前者更注重司法的程式正義，後者則更注重司法的實用效率。在有長期教義法學傳統，概念法學觀念盛行的國家，法經濟學確實有助於緩和法律的僵化，避免法律人在司法實踐中過度重視細節，而忽略全域。但中國當下的情況卻很不相同，我們長期忽略程序的重要性，而慣於追求實用。非但普通國民的認識如此，即使受過專門法律教育的人士也難倖免。有鑑於此，突出強調教義法學思維在司法實踐中作用，對於逐步形成中國的法治傳統意義不可低估。一則教義法學的思維有助於培養法官形成司法自制的意識，二則其強調公平正義在司法中的地位也更能贏得普通國民的認同。

二、法經濟學指導司法實踐有無優勢？

提倡法經濟學思維者以為教義法學方法老套，所謂教義，實為託詞，因此不足以指導司法實踐。而法經濟學則從「理性人思維」

⁴³ See COOTER & ULEN, *supra* note 22, at 93-94.

⁴⁴ 桑本謙（註1），頁1-25。

出發，為疑難案件的審理提供了一套切實可行的解決方案⁴⁵。那麼，法經濟學的思維是否確實在司法實踐中具有這種優勢呢？以下同樣運用桑本謙論及的幾個具體案例⁴⁶，對此問題加以考察。

（一）贈與撤銷案

桑本謙引用國內學者的著述⁴⁷，認為允許撤銷贈與契約的教義法學理由是「權利義務相一致」，然而，這一理由無法說明為何《合同法》不允許經過公證的贈與契約撤銷。同樣，英美法的「對價」理論也無法對此加以解釋。因此，教義法學的這些理論概念仿佛都成了「事後的正當化說辭」，而非「事前的判斷依據」。

首先需要指出的是桑本謙在此提出的問題⁴⁸，從教義法學的立場上看，並非一個司法實踐的問題，而是一個理論性的問題。因為《合同法》對此已有明確規定，司法實踐只需依法執行即可，也非所謂「難案」的情況。只有站在法經濟學拋卻法律文義的立場上，才可能讓這個問題成為一個有關司法實踐的問題——文義不足憑，效率價最高。

那麼，教義法學是否無法自圓其說呢？筆者無法就國內學者的觀點一一查證，但日本的教義法學者對此給出的理由則有所不同。通說見解認為之所以非要式贈與允許撤銷，而要式贈與不許撤銷，是因為形式要求有助於避免當事人的輕率行為⁴⁹。這種理論不但可以自圓其說，而且與現實主義法學大家Lon L. Fuller對對價的功能解釋不謀而合⁵⁰，可見教義也可以是尊重法律功能價值的。

45 桑本謙（註1），頁1-25。

46 同前註。

47 同前註。

48 同前註。

49 參見內田貴，民法II債權各論，頁158（1997年）；近江幸治，民法講義V契約法，頁119（1998年）。

50 See Lon L. Fuller, *Consideration and Form*, 41 COLUM. L. REV. 799 (1941).

最後，也是最為重要的，桑本謙對此的法經濟學解釋又是不是託詞呢⁵¹？這一解釋認為受贈人對贈與承諾的誤信可以被視同一場事故，因此能以較低成本避免這場事故者就該負擔事故的損失。

儘管雙方避免事故的預期成本在個案中無法比較，但法院卻會推定：讓Y提高些警惕要比讓X改變自己隨意許諾的生活習性更容易一些……這一推理的合理性在於：社會上像X一樣隨意許諾的人數量眾多，而像Y一樣粗心大意的人卻很罕見。並且，將責任分配給粗心大意者可以使法律『樹敵較少』，由此降低法律的管理成本。儘管一律執行贈與承諾，可以減少謊言和欺騙的數量，但由此產生的少量社會收益補償不了極度攀升的執行成本；相反，拒絕粗心大意者的索賠請求卻可以抑制訴訟的動機，減少訴訟的數量，降低法律的實施成本。此外，既然法律應該鼓勵人們去成長，就不應過分保護那些天真無邪的人們。畢竟，我們就生活在一個充滿謊言和欺騙的世界，這是法律無力改變的既定社會條件⁵²。

這一段引文提出了一系列觀點——如隨意許諾者多而輕信人言者少，減少謊言的收益不足以彌補執行成本的攀升，我們生活的社會充滿謊言——卻未提供具體的經驗證據作為支援。由此，其可以依憑的大概只有人們一般的直覺印象了，可這和教義法學求助人們普遍的公平觀又有何區別？況且，這裡的一些觀點恐怕很難贏得人們基於直覺的普遍贊同，也可能與經驗證據不符。比方說，由於我們生活的社會充滿謊言，所以我們應該允許撤銷贈與契約，那麼，一個合理的推論是，伴隨一個社會謊言數量的減少，我們就該看到不同的法律規則了。如果以社會信任度作為一個社會謊言多少的測

51 桑本謙（註1），頁1-25。

52 同前註。

度，中國和日本在此方面區別不小⁵³，但有關贈與契約撤銷的規則卻為何別無二致？

此外，假如法經濟學真的關注效率，那麼，引文的觀點恐怕也難以符合效率要求。首先，放任社會充斥謊言將令資訊辨識成本（verification cost）激增，逆向選擇問題惡化，增加交易成本，從而抑制資源的有效配置。這就是為何法經濟學分析贊同教義法學拒絕詐欺契約效力的原因⁵⁴。其次，即便一方的注意成本低於另一方，但只要雙方的注意都可能降低事故的概率，就降低事故的成本這一效率目標而言，讓一方完全負擔事故責任而另一方完全不負擔責任⁵⁵，通常是不能實現這一目標的。這也是對事故責任法進行經濟分析的一個共識性結論⁵⁶。最後，抑制謊言是否會增加訴訟數量從而增加法院的執行成本呢？答案也可能是否定的。在訴訟成本高於和解成本的條件下，理性的當事人只有對訴訟結果抱有不同的期待方才會選擇訴訟，否則應該和解。因此，訴訟數量往往不取決於法律規則的內容如何，而是法律規則的清晰程度⁵⁷。所以，除非有理由認為抑制謊言法律規則必然不如放縱謊言的規則清晰，否則訴訟數量未必因為規則內容變化而變化。

假如法經濟學的衷心在於效率，其利器在於經驗而非直覺，那麼，根據筆者的以上分析，桑本謙站在法經濟學立場上，為論證允許贈與契約撤銷而提出的這一系列觀點⁵⁸，或許也不得不被視為託

53 See EDELMAN TRUST BAROMETER, <http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/about-trust/global-results/> (last visited Nov. 10, 2014).

54 COOTER & ULEN, *supra* note 22, at 361.

55 即採用無責任或嚴格責任規則。

56 See John Prather Brown, *Toward an Economic Theory of Liability*, 2 J. LEGAL STUD. 323 (1973).

57 See George L. Priest & Benjamin Klein, *The Selection of Disputes for Litigation*, 13 J. LEGAL STUD. 1 (1984).

58 桑本謙（註1），頁1-25。

詞——言不由衷的表述——了。

（二）致電司機案

桑本謙提到的司機因行車過程中接聽電話而發生事故的案件⁵⁹，在主張法經濟學思維的學者看來，其實是因果關係與過失認定應當合二為一的問題。也就是說，只要借助邊際漢德公式（Hand Formula）認定某一行為具有過失，那麼，該行為就應被視為事故的法律上之原因⁶⁰。這種將因果關係虛無化的傾向自 Guido Calabresi 以來對侵權法的經濟分析產生了深遠的影響⁶¹。然而，需要指出的是：邊際漢德公式本身只有在假定了某些事實因素是事故的原因這一前提之下才得以成立的。簡言之，因果關係的認定在前，漢德公式的運用在後，兩者原本不是一回事。在經典的侵權法經濟分析模型中，基本的目標函數可以被寫作 $\min p(x)A + wx$ ⁶²。其含義為：侵權法的目標是將預期的事故損害與預防事故所需的成本之和最小化；其中預期的事故損害等於事故發生的概率 p 與一旦事故發生損害的規模 A 之乘積，而 x 則代表了會影響事故發生概率的諸因素。讀到這裡，細心的讀者可能已經發現了，選取 x ——而不選 y 或者 z 進入此目標函數本身，就已經包含了對因果關係的判斷，而這種判斷是不依賴於目標函數的——這個函數對選取的任何變數都適用。因此，這一經典的法經濟學思維實則隱含了因果關係判斷獨立於過失判斷，卻被誤認為二者是一回事。同時，經過以上分析，我們也不難看到，經濟分析方法並沒有給因果關係判斷增添任

59 桑本謙（註1），頁1-25。

60 桑本謙（註1）的表述略有不同：「在漫長的因果鏈上，只有那個在事先看來成本最低的環節或至少是成本合理的環節，才可能被認定為與事故的發生存在『法律上的因果關係』」。不過，可以看出其要旨在於通過漢德公式確定令成本最小化的行為方式。

61 See GUIDO CALABRESI, THE COST OF ACCIDENTS: A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS (1970).

62 See Brown, *supra* note 56. 邊際漢德公式其實就出自這一目標函數的一階條件。

何新的武器——它完全沒有涉及這一前置於過失判斷的問題。因此，美國法經濟學的先驅之一Robert D. Cooter教授才會認為：因果關係的認定根本上是涉及自由（liberty）的問題而非適用經濟分析的效率問題⁶³。

以致電司機案為例，比方說，為什麼不將汽車製造商的注意程度納入目標函數呢？假如汽車製造商改變設計，遮罩車內的通訊信號，不是可以降低事故概率嗎？對此，持法經濟學論者也許會說：因為改變設計的成本很高。但是，這只是回答了根據邊際漢德公式，汽車製造商不因被認定有過失的問題，而並沒有回答為什麼汽車製造商根本不被納入該公式考量的問題。在此，需要強調的是：即便存在能以最低成本減少事故概率的行為人，也不等於僅僅讓此一人採取行動是最有效率的——其他行為人可能不如該行為人那樣能低成本地降低事故概率，但其採取降低事故概率的行動的成本仍可以在邊際上低於由於這種概率的降低而帶來的收益。換言之，就是即便我不如你能降低風險，也不等於我什麼也不該做。我該做還是不該做，以及該做些什麼要依據邊際漢德公式確定。而將我的行為完全排除在該公式考慮的變數範圍之外，則等於預先假定我是什麼也不必做的。由此可見，法經濟學思維方式對於因果關係的處理不見得比教義法學多一些理智，少一分武斷。

說完了因果關係，我們再來考察過失認定方面法經濟學的思維是否較法教義學更有優勢。首先，我們應當承認，法經濟學確實為我們找到了一些重要的分析變數，有助於釐清問題的關鍵所在。不過，這一優勢或許更多體現在理論認知上，而非司法實踐上，因為司法實踐不僅需要找到變數，還需要將這些變數可操作化（operationalize）。而可操作化就包含了如何測量變數的值，假如無

⁶³ See Robert D. Cooter, *Torts as the Union of Liberty and Efficiency: An Essay on Causation*, 63 CHI.-KENT. L. REV. 523 (1987).

法做到這一點，那麼，法官即使知道了變數也只能跟著感覺走，頂多是猜測一番罷了。與教義法學相比，區別只是從猜測合理之人會如何行為⁶⁴，變成合理之人行為的成本－收益如何。這正是本文以上提到的經濟分析不定性的一個體現。況且，嚴格說來，法經濟學採用的上述目標函數是針對具體行為人的具體情況而定的，而並不存在什麼抽象的合理之人的標準，因為效率的最終評價依賴於純粹主觀的效用（utility）標準。因此，在效率指引下往往產生權利應如何歸屬不確定的情況⁶⁵。這樣一來，實際上在缺乏客觀度量的情況下，法經濟學的思維方法恐怕比法教義學的思維方法要求裁判者作更多的猜測——後者猜一次就夠了，而前者則每次都要猜。

最後，還應指出：在過失判斷問題上，「合理之人會如何行為」與「合理之人行為的成本－收益如何」完全可能是兩個不同的問題，而非如桑本謙所言⁶⁶，法官必然——至少是下意識地——在做成本－收益比較。法官權衡的也可能是其他有關公平正義的因素，例如行為人是否從造成損害的行為中獲得利益。實際上，例如《合同法》第406條有關受託人注意義務的規定就考慮了類似因素——雖然委託契約是否有償本身不會改變受託人避免事故發生的成本。

（三）小雞啄眼案

此案同時被法教義學的支持者與法經濟學的支持者引用⁶⁷，雙方對如何處理此案的結論並無不同，爭論似乎僅僅在於用誰的思路得出這一結果更加合適。不過，雙方均沒有說明判斷這種「合適」

64 教義法學目前對過失的認定主要採用客觀的合理人標準，參見王利明，民法，5版，頁567（2010年）；張新寶，侵權責任法原理，頁72（2005年）；內田貴（註49），頁314。

65 See Cooter, *supra* note 63, at 545-47.

66 桑本謙（註1），頁1-25。

67 孫笑俠（註1），頁1111；桑本謙（註1），頁1-25。

與否的標準是什麼，而只是各自在各自思維體系下推導出同樣的結論來，因此，自然也不可能說服對方自己的這一套思路更好。

從教義法學的思路出發，孫笑俠認為法律對於是否應當抵銷未成年受害人之監護人的過失規定不明，但從立法本意旨在考慮加害人與受害人的利益關係平衡出發，應當對法律進行擴大解釋，從而將受害人的過失擴大到受害人一方的過失⁶⁸。同時，孫笑俠也指出，這種解釋是具有實際上的法律依據的⁶⁹，即最高院的一則司法解釋⁷⁰。因此，以最高院司法解釋作為司法實踐中具有完全約束力的淵源（authority）論，則教義法學的這種解釋毋寧已經成為單純的依文義適用法律而已。此外，筆者還想補充：假如認為在此法律規定確實不明，那麼，還可以依比較法解釋方法得到同樣的結論。《民法通則》第131條的規定非但與日本民法第722條第2項內容類別相似，而且二者在民法體系中所處的位置亦類似，均位於有關侵權損害賠償中免除或減輕責任的條款之中⁷¹。可見二者應具有相當的可比性，而日本民法第722條第2項的解釋早就將「受害人一方」包含在適用過失相抵的物件之中⁷²。由此，就教義法學論，得出此等結論完全合適。

持法經濟學論者對上述解釋理論的攻擊是：其以解釋之名掩蓋求助目的、結果之實⁷³。筆者以為，這種批判並不恰當，原因是如前所言，求助目的、結果並非法經濟學的專利，早在法經濟學誕生之前，法教義學就已經接受了考察法律之目的，權衡適用之結果來解釋法律。目的解釋、目的性擴張等等均是教義法學的標準方法。

68 孫笑俠（註1），頁1105-1136。

69 同前註。

70 最高院就法律具體適用問題有權作出解釋，此點在我國法律實踐中概無疑問。

71 此種體系位置並非大陸法系民法的通例，參見王勝明，中華人民共和國侵權責任法釋義，2版，頁150（2013年）。

72 內田貴（註49），頁405。

73 桑本謙（註1），頁1-25。

具體就本案涉及的擴張解釋而論，法教義學者也不諱言其「亦有目的的上之考慮⁷⁴」，又何來包裝掩蓋之說呢？如前所述，究其實質，教義法學與法經濟學的分歧主要不在是否要考慮目的、結果，而在什麼目的、結果。持法經濟學論者將法律的目的全部歸結為效率，而教義法學者則會考慮其他目的——尤其是公平。因此，桑本謙認為孫笑俠所謂「達到某種平衡」必然走向成本－收益分析⁷⁵，其實並不盡然⁷⁶。例如，這種平衡也完全可以是在矯正正義意義上的：讓無過錯的被告承擔責任不符合矯正正義⁷⁷。需要指出的是：從行為人過錯出發的矯正正義與效率目的並不必然吻合。譬如，嚴格責任在某些情況下可能符合效率要求，但卻未必總能得到矯正正義的支持⁷⁸。

持法經濟學論者完全依賴成本－收益比較，認為由受害人一方採取注意以避免事故的成本低於由動物飼養人一方採取注意的成本。因此，應當讓未盡注意的受害人一方承擔部分損害⁷⁹。假如忽略法院為判決過失相抵而增添的額外成本，那麼，這種經濟分析大體也是合適的⁸⁰。問題在於：持法經濟學論者並沒有證明受害人一方的注意成本必然低於動物飼養人的注意成本。這一點恐怕也很難嚴謹證明，因為不僅如前所述，注意成本因人而異，而且會因為外部客觀條件而異⁸¹。在本案中，比如養了幾隻雞，地方多大，孩子

74 楊仁壽（註32），頁111。

75 桑本謙（註1），頁1-25。

76 同前註。

77 See DAN B. DOBBS, THE LAW OF TORTS 15 (2000).

78 See *id.* at 16.

79 桑本謙（註1），頁1-25。

80 在此，桑本謙（註1）不知為何沒有像在「贈犬撤銷」案中一樣考慮訴訟數量增加導致的法院執行成本增加。顯然，判決過失相抵與判決嚴格責任相比，法院的在每項訴訟中的裁量成本將增加。同時，由於過失相抵規則比嚴格責任規則更具有不確定性，也會增加訴訟的數量。

81 See Steven Shavell, *An Analysis of Causation and the Scope of Liability in the Law of Torts*, 9 J. LEGAL STUD. 463 (1980).

是男是女，母親是老是少，等等可能都是需要考慮的因素。於是，成本－收益分析的結論最終也是依賴於一般的直覺印象，這與教義法學用以判斷過失的合理人標準，或者矯正正義的觀念，求諸一般直覺印象的做法並無多少實質區別。

最為可惜的是，雙方在探討這個具體的法律適用——區別於法律規定的理由——問題時，恰恰都弄錯了應當適用的法律。本案若發生在《中華人民共和國侵權責任法》實施之前，則應適用《中華人民共和國民法通則》第127條。因其明言「由於受害人過錯造成損害的，動物飼養人或者管理人不承擔民事責任」，故而並無《民法通則》第131條適用之餘地，理由是特殊規則優於一般規則適用。對於此，相信法教義學者應無異議，而持法經濟學論者，除非全然不顧法律文義，一味推行成本－收益分析，否則，也應可以認可。於是，若案件於此期間發生，則雙方均會認可免除養雞人的責任。另一方面，假如此案發生在《侵權責任法》實施之後，則應適用該法第78條，於是，除非養雞人能證明受害人一方具有故意或重大過失，其必須承擔全部責任。在此，受害人一方的故意似乎無從談起。不過，究竟何為重大過失？筆者似乎既未見到教義法學者的說法⁸²，也沒發現法經濟學者的標準⁸³。倘若雙方都不能為養雞人找出個說法來，恐怕法律適用的結果就要讓雙方一同失望了。

從以上對小雞啄眼案的評論，我們似乎看不到教義法學的思維與法經濟學的思維有誰更勝一籌：在雙方擅長的領域，各自都有一套說法，而這套說法依據的都同樣是不怎麼精確的直覺印象，況且

82 例如，張新寶（註64），頁72，對重大過失的定義僅僅是「疏忽」與「輕信」之前加了「極度」二字而已。不過，王利明（註64），頁567，提出了違反一般人的注意構成重大過失的見解。

83 傳統的漢德公式顯然是不考慮過失是否重大的。至於其他法經濟學文獻，就筆者所知，似乎也未有涉及。原因也許是在法經濟學最為發達的美國，恰恰法律不認為重大過失（gross negligence）對侵權責任有何特殊影響，see DOBBS, *supra* note 77, at 349。

最終雙方的結論也無不同；反過來，對於困難的問題，雙方又同樣沒有好的解決方案。而當雙方代表在暢談法律人思維方法的時候，似乎都弄錯了適用的法律。

肆、誰的法律思維？（代結論）

在討論法律人的思維問題之前，或許我們先應該釐清「法律人」說的是誰？筆者以為：從事司法實踐者的思維方式與從事法律研究者的思維方式可以很不相同。前者不僅需要可行，更需要合法。可行指的是在司法實踐者的教育背景下，可以被他們普遍掌握；合法指的是司法實踐者的裁判方法能夠得到作為司法活動物件的民眾的普遍接受。從這兩個條件出發，本文認為司法實踐者——尤其是中國當下的司法實踐者——主要應當採用教義法學的思維方式。

一方面，法學教育仍是以教義法學為主要內容的。這不僅是中國法學教育的現狀，也是大陸法系各國以及英國的現狀，甚至也是法經濟學發軔之地美國的現狀⁸⁴。要求司法實踐者以法學院沒有系統傳授過的法經濟學思維來判斷案件，恐怕不切實際。當然，或許可以認為法學教育本身也可以改革。但是，如果改革的目標是讓從事司法實踐工作者普遍掌握經濟分析的思維方法，那麼，也許需要將法學院全面改造成應用經濟學院才行。筆者不敢預言這種改造計畫有多大的可能性。

⁸⁴ 筆者曾有幸就讀於哈佛（Harvard University）和柏克萊（University of California, Berkeley）兩所美國法學院。其間，筆者修習的所有部門法學課程——包括財產法、擔保法、公司法、契約法、版權法——都是以傳統的案例教學——相當於大陸法的教義法學——為主要的授課內容。

另一方面，以公平正義作為司法實踐的目標，以形式邏輯為這種實踐的基本表現形式，更加符合普通民眾對於司法應有之意的認知。教義法學縱然有概念黑箱，但至少這些黑箱被用公平正義包裝起來了，而這種包裝比法經濟學赤裸裸地提倡效率，似乎更可能贏得民眾的認同。顯然，一項根本改變民眾認知——由偏愛公平正義轉向偏愛效率——的社會革新恐怕過於任重道遠了。無論如何，如果要建設真正的法治，我們的任務是更多地強調程序的重要性，而非短路地考察結果。如前所述，這一法治建設的要求與教義法學而非法經濟學的思維愈加吻合。

簡單否定存在教義法學的思維也不盡合理。一則，如前所述，教義法學的進路確實與法經濟學的進路有所不同。二則，即便兩者確有共同的思維模式，例如形式邏輯的推理過程，也不足以認為教義法學的思維不存在。譬如，物理學與現代經濟學都運用了數理邏輯的思維方式，但這顯然不等於經濟學的思維方式就被物理學的思維吸收掉了。再以司法實踐的實際情況看，即便美國也不會直接選擇經濟學家來當法官。而如果法經濟學的思維方式才是正宗的法律人思維方式，那麼，法官的最佳人選就應當是受過專門訓練的應用經濟學家了。

當然，司法實踐會面臨許多無法通過簡單的文義解釋或者邏輯推演直接解答的問題。對此，教義法學也承認目的和結果考察的作用。此時，包括經濟學在內的各種社會科學以及人文學科都可以為司法實踐作出貢獻。而這種貢獻主要是提供知識——亦即基本可靠的事實——而非思維方式，更不應該代為設定目標。用一個形象的比喻，其他各學科可以提供多種食材、佐料，但燒什麼菜，燒成什麼味道，仍然應該由教義法學來掌勺。實際上，例如統計學就為司法實踐提供了很多有用的知識，但法官本身並不需要掌握統計學的技術或者思維方法。

與司法實踐者不同，法律研究者既不必受制於教育背景的限制，而研究基本也不存在合法性的問題。毋寧說，以追求真理為己任的研究者應當打破學科的界限，探索各種可能的接近真理的思維方式。實際上，跨學科研究已日益成為當下各個領域學術研究的共同特徵，法學研究自然也不應例外。然而，學術研究——尤其是科學性研究——的任務首先是揭示真理，而非推行某種價值觀。因此，嚴肅的科學研究應當謹慎對待規範性問題。同時，切實掌握教義法學的內容與思維對於從事法經濟學研究的學者同樣有積極意義。畢竟，假如法學研究者喪失了「法學的」知識，或者我們的學科喪失了基本陣地，那麼，我們又能為跨學科研究做些什麼呢？

最後，就中國的實際情況而言，教義法學者與法經濟學者確實應當加強溝通，深入理解各自的工作，而非片面地相互否定。記得Cooter教授曾言：「先知道法經濟學是什麼，再來批評法經濟學！」我想這句話也應當同樣適用於對待教義法學的態度。

參考文獻

1. 中文部分

- 王利明（2010），民法，5版，北京：中國人民大學出版社。
- 王勝明（2013），中華人民共和國侵權責任法釋義，2版，北京：法律出版社。
- 孫笑俠（2013），法律人思維的二元論兼與蘇力商榷，中外法學，2013年第6期，頁1105-1136。
- 秦暉（2013），共同的底線，南京：江蘇文藝出版社。
- 張新寶（2005），侵權責任法原理，北京：中國人民大學出版社。
- 張巍（2002），日本的抵押權滌除制度，民商法論叢，24卷，頁499-568。
- 梁慧星（1995），民法解釋學，北京：中國政法大學出版社。
- 楊仁壽（1999），法學方法論，北京：中國政法大學出版社。
- 蘇力（2013），法律人思維？，北大法律評論，2013年第2輯，頁429-469。

2. 外文部分

(1) 日文

- 加藤一郎（1974），民法における論理と利益衡量，東京：有斐閣。
- 近江幸治（1998），民法講義Ⅴ契約法，東京：成文堂。
- 桑本謙（2014），「法律人思维」是怎樣形成的——一個生態競爭的視角，法律和社會科學，2014年第1期，頁1-25。
- 内田貴（1997），民法Ⅱ債權各論，東京：東京大学出版会。
- （2000），民法Ⅰ總則・物權總論，2版，東京：東京大学出版会。

(2) 西文

- Ayres, Ian, and Eric Talley. 1995. Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade. *Yale Law Journal* 104:1027-1117.
- Ayres, Ian, and Paul M. Goldbart. 2003. Correlated Values in the Theory of Property and Liability Rules. *Journal of Legal Studies* 32:121-151.
- Bebchuk, Lucian Arye. 2001. Property Rights and Liability Rules: The Ex Ante View of the Cathedral. *Michigan Law Review* 100:601-639.
- Brown, John Prather. 1973. Toward an Economic Theory of Liability. *Journal of Legal Studies* 2:323-349.
- Calabresi, Guido. 1970. *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Coleman, Jules Leslie. 2003. The Grounds of Welfare. *Yale Law Journal* 112:1511-1543.
- Cooter, Robert D. 1987. Torts as the Union of Liberty and Efficiency: An Essay on Causation. *Chicago-Kent Law Review* 63:523-551.
- . 2000. *The Strategic Constitution*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Cooter, Robert D., and Thomas Ulen. 2012. *Law and Economics*. 6th ed. New York, NY: Pearson.
- Damaška, Mirjan R. 1991. *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dobbs, Dan B. 2000. *The Law of Torts*. Eagan, MN: West Group.
- Donahue, John J., and Justin Wolfers. 2006. Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate. *Stanford Law Review* 58:791-845.

- Doyle, William. 1987. The Parlements. Pp. 157-167 in *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture Volume 1: The Political Culture of the Old Regime*, edited by Keith Michael Baker. Oxford: Pergamon Press.
- Ellickson, Robert C. 1991. *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Forbes, Kristin J. 2000. A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth. *American Economic Review* 90:869-887.
- Fuller, Lon L. 1941. Consideration and Form. *Columbia Law Review* 41:799-824.
- Gallagher, Mary E. 2006. Mobilizing the Law in China: "Informed Disenchantment" and the Development of Legal Consciousness. *Law & Society Review* 40:783-816.
- Güth, Werner, Rolf Schmittberger, and Bernd Schwarze. 1982. An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining. *Journal of Economic Behavior & Organization* 3:367-388.
- Halter, Daniel, Manuel Oechslin, and Josef Zweimüller. 2014. Inequality and Growth: The Neglected Time Dimension. *Journal of Economic Growth* 19:81-104.
- Hilbink, Lisa. 2007. *Judges Beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Itoh, Hiroshi. 1990. Judicial Review and Judicial Activism in Japan. *Law and Contemporary Problems* 53:169-179.
- Jackson, Howell E., Louis Kaplow, Steven M. Shavell, W. Kip Viscusi, and David Cope. 2011. *Analytical Methods for Lawyers*. 2d ed. New York, NY: Foundation Press.
- Kaplow, Louis, and Steven Shavell. 1994. Why the Legal System Is Less Efficient Than the Income Tax in Redistributing Income. *Journal of*

- Legal Studies* 23:667-681.
- . 1996. Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis. *Harvard Law Review* 109:713-790.
- . 2002. *Fairness Versus Welfare*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Keefer, Philip, and Stephen Knack. 2002. Polarization, Property Rights and the Links Between Inequality and Growth. *Public Choice* 111:127-154.
- Knack, Stephen, and Philip Keefer. 1997. Does Inequality Harm Growth Only in Democracies? A Replication and Extension. *American Journal of Political Science* 41:323-332.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 1998. Law and Finance. *Journal of Political Economy* 106:1113-1155.
- Li, Ling. 2010. Corruption in China's Courts. Pp. 196-220 in *Judicial Independence in China: Lessons for Global Rule of Law Promotion*, edited by Randall Peerenboom. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lieberthal, Kenneth. 2003. *Governing China: From Revolution Through Reform*. 2d ed. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Liebman, Benjamin L. 2005. Watchdog or Demagogue? The Media in the Chinese Legal System. *Columbia Law Review* 105:1-157.
- . 2013. Malpractice Mobs: Medical Dispute Resolution in China. *Columbia Law Review* 113:181-264.
- Miceli, Thomas J., Henry J. Munneke, C.F. Sirmans, and Geoffrey K. Turnbull. 2002. Title Systems and Land Values. *Journal of Law & Economics* 45:565-582.
- Minzner, Carl F. 2009. Riots and Cover-ups: Counterproductive Control of Local Agents in China. *University of Pennsylvania Journal of*

- International Law* 31:53-123.
- . 2011. China's Turn Against Law. *American Journal of Comparative Law* 59:935-984.
- Peerenboom, Randall. 2002. *China's Long March Toward Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Persson, Torsten, and Guido Tabellini. 1994. Is Inequality Harmful for Growth?. *American Economic Review* 84:600-621.
- Posner, Eric A. 2003. Economic Analysis of Contract Law after Three Decades: Success or Failure?. *Yale Law Journal* 112:829-880.
- Posner, Richard A. 2012. Lecture to the Students in the Summer School in Law and Economics. Unpublished manuscript. The University of Chicago Law School, July 12.
- Priest, George L., and Benjamin Klein. 1984. The Selection of Disputes for Litigation. *Journal of Legal Studies* 13:1-55.
- Ramseyer, J. Mark, and Eric B. Rasmusen. 2003. *Measuring Judicial Independence: The Political Economy of Judging in Japan*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Shapiro, Martin. 1981. *Courts: A Comparative and Political Analysis*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Shavell, Steven. 1980. An Analysis of Causation and the Scope of Liability in the Law of Torts. *Journal of Legal Studies* 9:463-516.
- Stern, Rachel E. 2010. On the Frontlines: Making Decisions in Chinese Civil Environmental Lawsuits. *Law & Policy* 32:79-103.
- Tullock, Gordon. 1965. *The Politics of Bureaucracy*. New York, NY: Public Affairs.
- Zhang, Taisu. 2012. The Pragmatic Court: Reinterpreting the Supreme People's Court of China. *Columbia Journal of Asian Law* 25:1-61.

Law and Economics and Judicial Practices in China:

A Footnote to Lawyers' Way of Thinking

*Wei Zhang**

Abstract

This article endeavors to analyze the usefulness of law and economics in China's judicial practice based on the answers to the following two questions: 1) In what kind of judicial systems is the law and economics approach more likely to be adopted in adjudications? 2) In what kind of institutional environment should the law and economics approach not be adopted in judicial practices? The basic conclusion of this article is that the law and economics perspective should not be promoted in adjudications in China at the current stage. This article also identifies the methodological differences between doctrinal legal studies and the law and economics approach, and use several specific cases to compare these two methodologies.

KEYWORDS: law and economics, doctrinal legal studies, lawyers' way of thinking, judicial activism, judicial practice.

* Assistant Professor, School of Law, Singapore Management University.

